

著作权法中的公众使用权

刘 银 良

摘 要：规范分析有助于探究著作权制度的基础，并对著作权法律规范进行批判性审视。“作者—著作权”和“传播者—邻接权”是传统著作权法的两大基础，公众基本属被动角色。然而这并不能反映著作权制度的现实，亦难以全面体现著作权制度的基础法律关系。公众作为作品的使用者是不可或缺的主体，应享有作品使用权，“公众—使用权”应成为著作权法的第三基础。公众使用权可在著作权法下被设置为具有救济措施的可诉性权利。著作权法的三大基础分别对应着作品的创作者、传播者和使用者及其各自的权利。三方主体及其权利与义务互为支持，可构建完整的著作权法律规范体系，促进实现著作权法基本目标。基于重新阐释的著作权基础法律关系，我国著作权法可望构建更为公平、合理和有效率的著作权制度，并可对国际社会的著作权制度发展提供创新的经验借鉴。

关键词：著作权 邻接权 公众使用权 使用者权

作者刘银良，北京大学法学院教授（北京 100871）。

著作权制度是以促进社会文化发展为基础目标的知识产权制度，不仅属国内公共政策，也影响着国际知识产权秩序的形成。其制度演化史表明，契合于特定历史时期的著作权制度当时可能具有合理性，然而受科技、文化、产业和国际贸易等多重因素影响，其原有合理性可能减弱乃至消失，从而需要制度创新。我国著作权法虽经两次修正，理论界也进行了较长时间讨论，但包括合理使用制度在内的一些基础性制度并不完善，理论研究滞后。我国著作权法的立法及解释困境源于著作权法的基本规则无法回应新的时代需求。^① 时代变迁亦注定我国著作权立法需要从移植走向创新。^② 然而，制度的构建与运行皆需要合理的法律规范作为基础，没有规范的支撑就没有著作权制度创新。

作为连接现实社会与著作权法基本目标的载体，著作权法律规范能否在实践中

① 参见熊琦：《中国著作权立法中的制度创新》，《中国社会科学》2018年第7期。

② 参见李琛：《论我国著作权立法的新思路》，《中国版权》2011年第5期。

形成期待的法秩序，依赖法律规范能否体现并调整著作权基础法律关系，否则它就难以有现实合理性，也难以保证规范的现实效力。^① 著作权法调整的社会关系复杂，所涵盖的主体及行为亦有多多样性，除涉及作品的创作与传播外，还涉及作品的使用，与公众关系密切。然而，考察我国著作权法文本可发现，“公众”基本是隐含的角色，且处于被动状态，仅是作为作品（或表演）的接受者而存在。^② 虽然《著作权法》第 4 条明确规定著作权人行使著作权“不得损害公共利益”，但在现实中，鉴于“公共利益”的内涵与外延具有不确定性，该条款功能受限。著作权法下的公共利益保护一般是通过著作权（或邻接权）的限制或例外得以体现，其中尤其是合理使用制度。然而，我国《著作权法》第 22 条规定的著作权合理使用却存在内容不全面和体系不完整等问题，从而导致合理使用制度目标难以全面实现，并带来法律适用歧义，引发较多著作权纠纷。^③

在传统著作权法（尤其是作者权体系）理论框架下，作者和传播者是两种重要主体，他们分别基于作品的创作和传播享有著作权和邻接权。“作者—著作权”与“传播者—邻接权”是著作权法的两大基础，构成著作权制度的基础框架。然而，作者与传播者既非著作权制度现实中的全部行为主体，亦非全部权利与义务主体，作为作品使用者的公众，^④ 不仅是著作权法下的义务主体，事实上也享有相应的权利。忽略公众的权利主体资格的理论缺陷虽然在传统著作权法时代就已存在，但在数字互联网时代却体现得更为明显，由此导致的著作权制度结构性矛盾已不容回避。为此，有必要全面分析著作权法中的公众及其权利，进而建构合理的公众使用权制度。

一、著作权法中公众的类型化

在现行著作权制度中，公众作为作品使用者的角色多种多样，为实现著作权法规范目的，需要对其适当类型化。^⑤ 由于著作权法主要调整与作品相关的行为，以

① 凯尔森对于法律规范的阐述有助于理解著作权法律规范的涵义。See Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1945, pp. 29-40. (该书的新版中译本见凯尔森：《法与国家的一般理论》，沈宗灵译，北京：商务印书馆，2013 年)

② 在我国现行《著作权法》（2010 年修正）文本中，含有“公众”的条款包括：第 10 条第 1 款第 6、11、12 项；第 22 条第 1 款第 5、9 项；第 38 条第 1 款第 6 项；第 42 条；第 48 条第 1、3、4 项。

③ 参见熊琦：《论著作权合理使用制度的适用范围》，《法学家》2011 年第 1 期。

④ See Julie E. Cohen, “The Place of the User in Copyright Law,” *Fordham Law Review*, vol. 74, 2005, pp. 347-379.

⑤ See Pascale Chapdelaine, “Copyright User Rights and Remedies: An Access to Justice Perspective,” *Laws*, vol. 7, no. 3, 2018, pp. 15-22.

该类行为及其目的为标准对公众进行类型化，实为合理选择。依据作品使用目的，可把公众分为作品的消费者、再创作者和信息提供者三类，他们可统称为作品的“使用者”。^① 在本文中，“公众”与作品使用者等义。

（一）作品的消费者

作品的使用者可为学习、研究或欣赏等目的消费作品，其实质是获得作品的内容，包括隐含的思想或信息。作品的消费者藉由作品或其表演的载体（包括书籍、音像载体或载体信号）或现场表演等方式获得作品，然后通过阅读或观看等方式消费作品。使用者使用作品的各类行为可交织在一起，从而有利于实现著作权法推动社会文化发展的基本目标。^② 公众获得作品是其学习、研究或欣赏的前提，获得作品的方式包括无偿与有偿，无偿方式包括通过免费的图书馆、表演、广播或网络传播等，有偿方式包括通过购买作品或其表演的载体、演出门票或网络播放许可等。无偿获得方式是有偿获得的有效补充，因为无偿获得既可替代有偿获得，也可刺激有偿获得。藉由消费者支持，作者或传播者的著作权或邻接权利益可得到维护，著作权制度的激励效应可得以实现。不唯如此，消费者通过阅读和欣赏作品，可学习、认识或感受作品的科学、文学或艺术价值，从而对作品和作者产生认同，作者亦可在获得经济利益的同时获得精神收益。

在“作者—（作品）—读者”的传播与使用链条中，作品是媒介和枢纽，作者创作了作品，但作品一旦发表就成为社会文化的独立存在，是读者的阅读使作品的生命得以延续，并在人类文化中传承。读者对作品并非简单接收，而是需要对作品进行理解或诠释，有批评者甚至认为作品完成作者即死亡。^③ 在与作者的关系中，读者并非被动，因为作品是为读者创作，只有通过读者的阅读才使作品文本的解读最终确定，作品才能够真正存在。^④ 这提示，读者并非被动的信息接收者，他们具有现实的主动性。读者不仅是作品的消费者，还可构成作品或作者精神的传承者，对作品起到欣赏、诠释、继承乃至发扬光大的作用。甚至在作品创作中读者的角色也可能存在，包括对创作的指引。作者在创作叙事、评论或小说等作品时，均可能意识到其作品的构思与表达如何能够为读者所理解或接受。作者寻求读者认同的心理，可激励其关注读者对作品的接受模式，选择可能促进其与读者交流的模式进行

① 著作权法下的“使用者”一般指使用他人作品的人。参见吴汉东：《著作权合理使用制度研究》，北京：中国人民大学出版社，2013年，第117页。

② Julie E. Cohen, “The Place of the User in Copyright Law,” pp. 370-374.

③ 参见左其福：《语言学转向背景下作者死亡论的比较考察——以罗兰·巴特和福柯为对象》，《当代文坛》2009年第2期。

④ 参见王秋月：《作者与读者的潜在对话——试析冯塔纳的小说〈施泰希林〉》，《德国研究》2019年第2期。

创作。此种创作心理有助于增加作者和读者的交流，亦有益于拓展作品市场和促进实现其市场价值。概言之，在作品的创作与传播中，作者与读者互为依存和支持：读者对作品的欣赏固然依靠作者创作出优秀作品，但作者亦需依赖读者理解其作品的思想、内容或品质，否则作品可能难以得到有效传播。

由作品创作和传播所引发的作者与读者精神上的交流，甚至可能比读者作为作品消费者的单纯经济涵义更重要。对于作者而言，读者对其作品的认同属于精神上的激励，更为珍贵。正是读者在精神层次对作品的认同，才可能支撑其经济层次的消费，否则该作品就可能没有相对持久的消费市场，其市场价值将难以保证。很多无价值的作品在人类文化遗产中并无地位，其版权产业的价值亦难以体现。读者在精神层次对作品的认同，也可促进其对作品内含的思想或信息的学习或研究，进而推动作品传播与传承，使作品的社会价值得以实现。消费者通过学习、研究或欣赏作品，其个人的知识、思想、素养等可得到提升，社会整体文化素质和创新能力亦有望提高。

上述表明，作品的学习者、研究者或欣赏者对于作品的传播乃至创作具有重要作用。在作者与读者的二元关系中，公众看似属于被动的消费者，但他们也具有主动地位，其对作品的认同和消费直接决定了作品的传播范围及其文化和市场价值，也决定着版权产业的规模、质量和可持续性。作者虽然创作了作品，著作权法也为其赋予专有的著作权，但其角色及影响是有限的，其著作权也应受到限制。

（二）作品的再创作者

公众还可能是作品的再创作者，对作品进行评论、戏仿或演绎。与消费者主要是为获得作品的思想或信息不同，再创作者既可能需要使用作品的思想或信息，也可能需要使用作品的表达，从而可能涉及更多著作权问题。作品的使用者针对作品的思想或表达进行评论或批评，可使作品优劣得到昭示，其对于文化、科学、教育或社会的益处得到更好体现，从而可能影响作品传播的速度、深度和广度。在文学、艺术或知识传播领域，评论意味着在作者和读者之间产生了交流。在学术领域，如文学与文学批评、艺术与艺术批评等学术对峙，亦体现出知识创新与学术探索的必要逻辑。无论是在文化或娱乐领域，还是在学术领域，皆是无批评则无交流，亦无理性的文化传承和发展，公众对于作品的评论因而有益于著作权法基本目标的实现。

公众还可借鉴已有作品创作新作品，使文化在得以传承的同时亦可得到创新，文化长河不断有源头活水。评论也可能体现为评论者的戏仿作品或演绎作品，在演绎作品中还有较为特殊的同人作品。无论是戏仿作品还是同人作品，都涉及是否侵犯原作者著作权的判断。任何作品的创作都离不开对已有作品的借鉴，即使是具有高度原创性和创造力的作者也是如此。借鉴前人作品既是作品创作的必经之路，也是社会文化得以传承和创新的必要方式。在文化中积累的知识、思想或表达等被有

效传承，可便利公众对于作品的学习、研究或欣赏，使文化得以有效延续。在数字互联网时代，公众既可以方便地成为作品的评论者，评论或批评原作品，也可以创作新作品，使文化表达更具多样性，亦为文化传承和发展提供素材。大众创作与传播也有利于维护文化多样性和稳定性，避免文化衰落。在数字互联网等创作及传播技术支持下，人们利用他人作品或传播平台的再创作形式更为多样，这既扩展了互联网内容产业，激励公众创作、传播和消费作品，又有助于促进作品市场价值实现。

无论是评论者或演绎作者，其创作的评论、戏仿或演绎作品等都可能涉及对原作品内容的使用，其中包括作品的表达，因而可能触及原作品作者的著作权。如果再创作者过度使用了原作品的表达，就可能超越合理使用的范畴，引发是否侵犯著作权的争议。

（三）信息提供者

作品使用者还包括机构使用者，如图书馆、学校、研究所等具有公益性质的文化、教育或科研机构。在数字互联网时代，还有数字图书馆、网络书店以及作为作品或信息提供者的信息搜索平台等网络服务提供者（ISP）。互联网环境下的信息提供行为涉及互联网搜索引擎的索引、信息抓取、提供摘要或缩略图等，还有数字图书馆或网络书店为介绍或促销图书以在线预览等方式向读者提供少量作品内容等。^① 随着大数据和人工智能的应用，被分析和应用的数据（作品）更为多样，分析可能更为科学与快捷，得到的信息或成果可被广泛应用，具有重要的社会价值和产业价值。

从作品及其内含的思想或信息的传播角度看，这些机构使用者实质上属于信息提供者，即通过向消费者提供作品信息的方式使用作品。作为信息提供者的机构实质相当于个人使用者的代理人、代表人或中介机构，如图书馆购买并出借图书仍然是为读者个人使用，互联网信息提供者也主要是为一般使用者提供信息搜索或链接服务。信息提供者一般具有法人资格，在著作权合理使用制度下它们可作为独立的作品使用者被规范。一些信息提供者还可能同时作为作品传播者而承担相应的义务并享有邻接权，这与其作为信息提供者可能享有的权利并不冲突。

（四）作者、传播者与公众

在传统著作权法理论及规范体系下，公众的角色长期被忽略。以上类型化分析表明，公众作为作品的消费者、再创作者或信息提供者，在作品的获得、使用、再创作和传播等各环节，皆属不可或缺的角色，他们既是版权产业的支持者和参与者，也是文化的传承者和创新者，是决定作品市场价值和文化价值的重要力量。如果作品不被公众接受，不仅其市场价值不能得到实现，文化价值亦难以体现，很多作品

^① 参见梁志文：《著作权合理使用的类型化》，《华东政法大学学报》2012年第3期。

正是因为没有读者而在文化中消散。在版权产业链条中,除需上游的作者供应多样化的作品外,还需下游的使用者持续支持,版权产业才可能持续发展。

作者、传播者和使用者之间具有互相支持与制约的关系。在数字互联网等技术支撑的大众创作与传播时代,作品的创作、传播与使用以及各主体之间的界限越来越模糊,各主体的角色易发生交叉或转换,厘清各主体的特点及其著作权法涵义至为重要。首先,三方主体的角色可发生转换。作品的作者可以同时成为作品的传播者,而传播者亦可通过受让著作权或接受许可而成为著作权人或被许可人,并且使用者皆可通过创作作品成为作者而享有著作权,或通过合法传播作品成为传播者而享有邻接权。同样地,任何作者或传播者(个人)亦属他人作品使用者,即使是知名的作者或表演者也获得和使用他人的作品或表演,从而属于使用者。其次,任何人皆可同时拥有作者、传播者和使用者三种身份。任何人既可以通过创作作品享有著作权,也可以作为其作品或他人作品的传播者而享有邻接权,也可以同时作为使用者使用他人的作品。著作权法下各类主体的可转换性意味着在作品的创作者、传播者和使用者之间并无绝对的界限。加之现代社会几乎每个人皆属著作权法下的使用者,著作权法需认真对待公众的角色及其正当权利,而这正是传统著作权法理论和法律规范所忽视的。正因如此,著作权法正在重新认识作品使用者的角色,使用者正在从著作权法的边缘走入中心,与作者一起成为核心要素。^①

以上分析,从法律关系角度看,围绕着作品的创作、传播和使用,作者、传播者与使用者及其各自的权利与义务构成著作权法下的基础法律关系,其中作者、传播者与使用者皆属不可或缺的主体,而三方主体的权利与义务则属必要的权利与义务设置。这些基础法律关系的各要素皆需在著作权法律规范中得以体现,从而使著作权法律规范体系得以合理构建,否则著作权法就难以全面涵盖真实的著作权基础法律关系,良好的著作权法秩序将难以形成。

二、公众使用权的法理基础

创作者、传播者与使用者三方主体各自的权利与义务如何设置是著作权法的基础问题。著作权法基本目标的实现依赖作品的创作、传播与使用。无作品创作,则无作品可传播,亦无作品的获得和使用,作品的社会或文化价值将难以实现。就促进实现著作权法基本目标而言,作品的创作、传播与使用三种行为缺一不可,皆属著作权法所应规范的基础行为。著作权法理论除需关注作者及传播者的权利外,还应关注使用者的权利,相应的著作权法律规范才可能涵盖所有权利与义务主体,体

^① 参见朱理:《著作权的边界——信息社会著作权的限制与例外研究》,北京:北京大学出版社,2011年,第202页。

现著作权制度的现实合理性。就此而言，传统著作权法理论对于公众的角色及其权利缺乏充分的关注与论证，现行著作权法律规范亦无关于公众权利的相应规定。^①作品使用者的角色及权利的缺位不仅可能影响著作权合理使用行为的判断，也会产生“波及著作权法结构的多米诺效应。这既塑造了公认的规则，也导致了最棘手的困境。均衡良好的著作权大厦本应有的基础却成为空白。该失衡造成了不好的理论、不好的政策和不好的法律。”^② 鉴于著作权法中使用者主体及其权利缺失已致不利后果，著作权法理论及规范应关注作品使用者的主体资格及其权利。

（一）使用者权概念反思

为弥补传统著作权法的理论缺陷，“公众获得权”和“使用者权”等概念被提出。公众获得权即公众获得受著作权保护的作品的权利。^③ 但也有研究者把作者控制其作品在互联网环境下被公众获得的权利称为“获得（获取）权”或“接触权”。^④ 可见这两种“获得权”的涵义正好相反。如果运用公众获得权概念，从其字面含义看，容易理解为仅赋予公众获得作品的权利。因此除可能引起歧义外，其权利范畴也被限缩。当今，国际上更有影响的是“使用者权”，即公众作为作品使用者所享有的权利。美国有学者认为，版权法赋予作者权利，亦需赋予作品使用者权利，使用者权是不容忽视的权利。“作者、出版者和消费者皆是版权资料的使用者，此即为何版权法是由三部分组成，即作者权的法律、出版者权的法律和使用者的法律”。^⑤ 作者的权利和使用者的权利“务必需要权衡和互相平衡”。^⑥

加拿大最高法院首开司法认定使用者权先河。在知名的 CCH Canadian 案中，被告图书馆为读者提供作品复印件服务。加拿大最高法院认为：“把合理使用例外理解为版权法的内在部分，而非仅是简单的抗辩，可能更为合适。任何落入合理使用例外的行为都不是侵犯版权的行为。合理使用例外和版权法中的其他例外一样，是一种使用者权。为维持版权所有者的权利和使用者利益的平衡，它不应被限制性地解释。”^⑦ 法院认为版权法有双重目标，其一是维护公共利益，其二是藉由公众的支

① Julie E. Cohen, “The Place of the User in Copyright Law,” p. 348.

② Julie E. Cohen, “The Place of the User in Copyright Law,” pp. 347-348.

③ L. Ray Patterson and Stanley W. Lindberg, *The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights*, Athens and London: The University of Georgia Press, 1991, pp. 57-71.

④ 参见彭学龙：《论著作权语境下的获取权》，《法商研究》2010年第4期；熊琦：《论“接触权”——著作财产权类型化的不足与克服》，《法律科学》2008年第5期。

⑤ L. Ray Patterson and Stanley W. Lindberg, *The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights*, pp. 3-4.

⑥ L. Ray Patterson and Stanley W. Lindberg, *The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights*, p. 207.

⑦ CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13, para. 48.

持使作者获得经济收入,版权法需在两目标之间达到合理的平衡。^①加拿大最高法院的判决明确提出合理使用属于使用者权,戏剧性地扩张了合理使用的范畴,引导法院对于合理使用做出宽泛解释。^②

我国有学者在引入使用者权的同时也进一步论证了该权利,认为它具有受法律保护的利益、由法律所允许的自由和由法律所认可的意志三种权利要素,并且还具有一般民事权利的基本特征,其中包括法律保障性。^③也有研究者认为使用者权概念有利于著作权合理使用制度构建,因为在传统著作权法理论下权利的限制与例外基本被视为侵权抗辩事由,但使用者权“已经不再限于对权利主张的抗辩,而是与版权直接抗衡的权利,构成版权不能逾越的屏障。”^④

然而,从法律规范的构造看,“使用者权”强调公众作为作品使用者的权利,是从权利主体即公众的使用者身份出发主张权利,这虽然是一种权利设置路径,但此种以权利主体身份为特征所界定的权利有多种缺陷,可导致法律规范的不确定性。其一,作品使用者内涵广泛,具有多样性与复杂性,至少包括个人消费者和再创作者以及作为信息提供者的机构,作为法人的机构与一般公众成员性质不同。其二,作品使用者拥有多样化的权利,包括宪法权利和多种民事权利,它们难以具有相同的法理基础和法律规范结构。其三,使用者权具体指代何种权利不明确,权利范畴不清晰,权利的边界无法确定,因而也难以获得概括性的论证和理论支撑。因此,虽然加拿大最高法院已经在案件判决中认可该权利,但研究者仍认为使用者权概念具有法律上的不确定性。^⑤

由是观之,虽然使用者权概念的提出突破了传统著作权法理论,是一种有益尝试,但从法律规范角度看,其权利构成、行为范畴、权利的边界乃至救济方式等皆有不不确定性,规范的效果难以保证。从立法角度看,如此缺乏确定性的权利概念显然难以为著作权法律规范所吸收。尽管有多国研究者提出或引进使用者权概念,但立法者尚难以在著作权法律规范中明确规定该权利。只有确定的和具有清晰边界的权利概念才适合规定在著作权法律规范中,从而有助于构建合理与完整的著作权法律规范体系。

(二) 公众使用权的必要性

基于以上对著作权法中公众角色的分析,本文主张赋予作品使用者即公众正当

① CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13, para. 10.

② See Parveen Esmail, “CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada: Case Comment on a Landmark Copyright Case,” *Appeal*, vol.10, no.1, 2005, pp. 18-21.

③ 参见吴汉东:《著作权合理使用制度研究》,第117—122页。

④ 薛虹:《论开放的权利限制与例外》,《中国版权》2012年第6期。

⑤ See Pascale Chapdelaine, “The Ambiguous Nature of Copyright Users’ Rights,” *Intellectual Property Journal*, vol.26, 2013, pp.44-45.

使用作品的权利，可称“公众使用权”或“使用权”。公众使用权就是公众成员依法通过消费、再创作或提供信息等方式使用作品的权利。虽然在现行著作权法下，藉由著作权合理使用制度，公众使用权的部分内容已有所规定，但由于著作权合理使用制度并不能涵盖公众使用权的全部内容，且合理使用一般仅能作为侵权抗辩事由，故仍有探讨该权利并在著作权法律规范下设置该权利的必要。著作权法的基本目标是促进社会文化发展，赋予作者著作权仅是工具性措施。著作权（版权）法需在促进知识进步和保护作者著作权利益之间做出协调，前者是目标，后者是功能或工具。^① 美国联邦最高法院从版权制度的基本目标出发强调版权与公共利益的平衡，其中公共利益包括思想、信息和商业的自由流动。^② 在传统著作权法理论和法律规范体系下，虽然“公共利益”成为防御著作权扩张的概括性理由，似乎具有无所不包的内涵，但同时它却没有坚实的著作权法律规范支撑。相应地，研究者或司法裁判者虽然习惯把公共利益作为论证利益平衡的理由，但是当公共利益与著作权对峙时却经常处于防御地位，仅能被用作侵权抗辩事由，难以全面维护公众的权利和利益。

公共利益之所以成为著作权法中的弱势抗辩理由，有多方面的原因。第一，传统著作权法理论并未赋予公共利益足够坚实的内容，它仅能代表抽象的利益，因而难以对抗具体的著作权。第二，维护著作权法基本目标的实现也是著作权法的公共利益，甚至可以说是著作权法语境下最大的公共利益，与此相关，保护著作权从而促进作品的创作与传播亦是促进实现著作权法基本目标的手段，它因而也是公共利益所需维护的对象，这显然为论证限制著作权带来内在困境。第三，在《伯尔尼公约》、世界知识产权组织《版权条约》（WCT）、TRIPS 协议等国际著作权条约下，公共利益主要适用于为教育、公共图书馆、个人复制等情形，且仅能作为侵权抗辩事由。^③ 基于这些因素，公共利益虽然属于较为常用的利益平衡理由，但却难以全面保障公众的利益。

为此，在现行著作权法律规范体系下，当与具体著作权冲突时，概括性的公共利益一般需要避让。在伯尔尼公约、WCT、TRIPS 等国际条约或国内著作权法语境下，对著作权是否可以施加限制，需由“三步检验法”^④ 加以验证。得到“三步检

① See L. Ray Patterson and Stanley F. Birch, Jr., “A Unified Theory of Copyright,” *Houston Law Review*, vol.46, no.215, 2009, pp.335-336.

② See *Sony v. Universal*, 464 U.S. 417, 429, 431-432 (1984).

③ See Mihaly Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, Their Interpretation and Implementation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, paras. 5.55-5.58, C10.03.

④ “三步检验法”即著作权限制措施需满足特定情形、不与作品的正常利用相冲突、不得合理地损及作者的合法利益三个条件。参见刘银良：《我国广播权法定许可的国际法基础暨修法路径》，《清华法学》2019年第2期。

验法”认可的著作权利限制或例外，就基本决定了传统著作权法理论中“公共利益”的范畴。这意味着，公共利益将止步于“三步检验法”所允许行为的集合。公共利益的维护仅能到此为止，其在著作权法下的弱势符合传统著作权法理论的逻辑。究其根本，在于著作权法理论中的公共利益不仅包括使用者的利益，也包括作者和传播者的利益，乃至包括整个著作权制度目标所维护的利益。

既然概括性的公共利益并非总能够维护公众的利益，著作权法就需另辟有益的权利设置路径。只有赋予公众边界清晰的确定性权利，其利益才可能得到保障，本文主张的公众使用权即属此类。公众使用权可望有助于充实著作权法下公共利益的概念，使其内涵具体化，并可固定在著作权法律规范中，从而将使用者的权利体现为与著作权或邻接权相制衡的权利。公众使用权的必要性源自以下多方面的理由。

第一，从防御角度维护著作权法的基本目标。著作权仅属为实现著作权法基本目标的制度工具，具有有限性。^①但在著作权制度现实中，著作权却拥有强势地位，并随着技术发展而呈现不断扩张的趋势。尤其在数字互联网时代，著作权人应用的技术措施可能突破维护其著作权利益的合理范畴，造成限制公众获得或使用作品的后果。伴随着著作权的扩张及其技术保护措施的延伸，使用者的利益可能受到挤压，公共利益更为弱势。为促进实现其基本目标，著作权法需为著作权设置必要的限制，公众使用权可望是一种有效方式。如果公众享有作品使用权，就不用担心著作权扩张对其利益产生过度影响。

第二，从积极角度维护著作权法的基本目标。著作权法基本目标的实现离不开使用者的参与和支持，著作权法需要充分考虑公众的权利，保证其在获得与使用作品中的利益。著作权法需考虑各方主体的权利或利益平衡，既应鼓励作品的创作和传播，也应鼓励公众对作品的正当使用，以促进社会文化发展。作品是文化的重要载体，随着技术发展，社会公众可通过各种传统的或数字的方式获得作品，从而成为作品的消费者。公众消费作品既是著作权法下的作品使用行为，也是其获得知识、信息和思想进而提高其知识和认识的过程，因而是其社会文化生活的必要组成部分。使用者亦可评论作品或创作新作品，或提供作品的信息，从而有利于文化创新、发展与传承。

第三，有助于构建合理的著作权法律规范体系。从法律制度角度看，法律规范的构建与运行需要各主体配合，其各自的权利与义务需互相支持。著作权法的有效运行也需创作者、传播者与使用者互相支持。著作权法理论应有助于立法者合理分配创作者、传播者和使用者的权利与义务，使著作权法服务于知识的创造、传播和使用中的公共利益。^②各主体具有互助和互惠关系，在著作权法已经分别为作者和

① 参见刘银良：《著作权兜底条款的是非与选择》，《法学》2019 年第 11 期。

② L. Ray Patterson and Stanley F. Birch, Jr., “A Unified Theory of Copyright,” p. 383.

传播者设置了著作权和邻接权情形下，公众的作品使用权亦需得到合理设置，才可能在著作权法中构筑完整的权利与义务规范体系。

第四，有利于保障作品的合理使用与传播。在现实中存在使用者虽然认为其作品使用行为应属于合理使用，却因为担心被诉侵权而放弃使用的情形。在没有对抗性权利的情形下，著作权人也可能为排除竞争或限制他人合理使用提起侵权之诉，从而产生限制正当竞争和妨碍合理使用的后果。这都可能导致创作或传播成本增高，也限制了作品传播。在著作权保护越来越严格的情形下，单纯的侵权抗辩已难以全面承担合理使用的积极涵义，使用者正当的使用行为及其利益可能受到侵蚀。从预期效果看，设置公众使用权可望鼓励公众使用作品，防止使用者因担心被诉侵权而放弃使用作品或寻求不必要的许可，有助于保障各方利益平衡。

第五，促进版权产业理性发展。在数字互联网和大数据等技术支撑下的大众创作与传播时代，赋予公众合理的作品使用权可能促进版权产业理性发展，因为著作权合理使用制度可激励合理使用产业，该产业也属版权产业不可或缺的组成部分。^①

（三）公众使用权的规范基础

在国际公约框架下，人们有科学与文化权、表达自由权和信息自由权等基本权利。科学与文化权包括人们参与文化生活、得享科学进步及其应用利益的权利。《世界人权宣言》第 27 条第 1 款规定人们有权自由参加社会文化生活，享受艺术，并分享科学进步及其利益。《经济、社会和文化权利国际公约》也规定人们有参与文化生活和得享科学进步及其应用利益的权利。^②《世界人权宣言》第 19 条和《公民与政治权利国际公约》第 19 条也分别规定了人们享有表达自由权和信息自由权。

国际人权公约之所以赋予人们科学与文化权和信息自由权等，是因为现代社会的每个人都是文化的构建者和传承者，社会文化的进步依赖于全体成员的知识、文化修养与素质。学习科学、文学或艺术等知识，获得有价值的信息和思想，得享科学进步及其应用成果，进而创作出更多有价值的作品，不仅是公众的基本权利，甚至也是其基本义务，目的是保障文化的传承与延续。表达自由也属基本权利，包括评论他人作品以及利用他人作品创作新作品的权利。在信息自由和表达自由等权利支持下，公众可对各领域的知识和思想有所认知，并在其基础上加以创新，创作出科学、文学或艺术等领域的新作品。

国际人权公约规定的科学与文化权等基本权利在我国宪法中分别通过国家义务和公民权利两方面得以体现。从国家义务角度看，宪法规定国家发展教育和科学事

① See Rachel Storch, "Copyright Vigilantism," *Stanford Technology Law Review*, vol. 16, 2013, pp.453, 457.

② See UN General Assembly, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," United Nations, 16 December 1966, Article 15.1(a)(b).

业,发展文学艺术、新闻传播、出版、图书馆和博物馆等文化事业。^①促进文化和科学事业发展亦属著作权法基本目标,该目标的实现需依赖作品的创作、传播和使用,因此国家在教育、科学与文化领域的宪法义务恰对应着著作权法的基本目标及其运行。这意味着,为促进教育、科学和文化发展,国家有义务设置合理的著作权制度,维护公众在教育、科学和文化事业中的权利,其中包括正当使用作品的权利,以促进实现著作权法的基本目标。这也同时有助于实现国家发展教育、科学和文化的宪法义务。

从公民权利角度看,宪法分别规定了表达自由权与出版自由权、受教育权、科学自由权、创作自由权和文化活动自由权。^②这是公民享有信息自由、表达或创作自由、受教育以及参与文化活动等多种权利的宪法依据,可涵盖人权公约中的科学与文化权、表达自由权和信息自由权等权利。人们为学习或接受教育,或者从事科学研究、文学或艺术创作以及参与文化生活等,需要获得、使用、评论乃至创作作品。因此,为促进实现人们享有的科学与文化权、受教育权、表达自由权和信息自由权等宪法权利,公众需要享有合理使用作品的权利,人们享有的宪法权利构成著作权法下公众使用权的宪法基础。

质言之,宪法规定发展教育、科学和文化事业的国家义务和社会目标,是我国著作权法基本目标的宪法渊源。国家一方面需为保证实现公民的基本权利提供设施或条件,另一方面也不得随意限制乃至侵犯个人的基本权利,这分属国家义务的两个方面。^③人们享有的科学与文化权等基本权利属于公众使用权的宪法渊源。公众使用权有切实的宪法依据,符合国家促进教育、科学和文化事业发展的公共政策。

国际人权公约和我国宪法对于公民基本权利的规定既为公众使用权提供了国际法和宪法的规范渊源,也为其确立了法理基础。在其支撑下,公众使用权可成为著作权法下的实在权利,一方面可制约著作权的过度扩张,另一方面又可维护公众对于作品的正当使用,推动实现著作权法基本目标。促进社会文化和科学事业发展、保障信息自由和知识获取、便利作品创作与传播、维护公共利益、促进版权产业发展等制度目标,可支持论证公众使用权的必要性与正当性。公众使用权虽然具有国际人权公约和宪法基础,但它仍然属于著作权法下的民事权利。

三、公众使用权的结构

著作权法律规范的构造需要以立法者对著作权制度的现实和法律关系的正确理

① 参见我国《宪法》第 19 条、第 20 条、第 22 条第 1 款。

② 参见我国《宪法》第 35 条、第 46 条第 1 款、第 47 条。

③ 参见朱理:《合理使用的法律属性——使用者的权利、著作权的限制还是其他》,《电子知识产权》2010 年第 3 期。

解为前提，否则就难以保障合理的著作权法律规范。通过以上对著作权制度的现实和法律关系的阐释，藉由法律规范的构造及逻辑，或可重塑著作权法律规范体系，其中尤其是涉及公众使用权的规范。在确定的法律规范下，权利的结构包括权利主体、客体、主体的行为及其利益等要素。^① 公众使用权的构成可从权利主体、客体、权利所规范的行为等方面予以阐释。公众使用权也可进一步类型化，其边界亦可从其与著作权和邻接权的平衡中得以确定。

（一）公众使用权的主体与客体

公众使用权的主体是公众成员即作品使用者。使用者可分为消费者、再创作者和信息提供者三类，其中消费者包括学习者、研究者或欣赏者等，再创作者包括评论者、戏仿者或演绎者等，信息提供者包括传统或互联网空间的信息提供者，如传统图书馆、数字图书馆或互联网信息搜索平台等。因此可享有使用权的公众包括消费者、再创作者和信息提供者，其中消费者或再创作者为个人，信息提供者一般为法人。个人使用者也具有使用作品或再创作作品并追求其精神或经济利益的行为自由和意志。^②

作品是著作权制度的基础，也是作者的著作权、传播者的邻接权和公众使用权所共同指向的客体，只是不同的权利所规范的行为不同。作者因创作作品而享有著作权，其著作权可规范作品的复制、发行、传播、表演或演绎等行为。传播者因传播作品而享有邻接权，其邻接权可规范作品的传播行为，包括表演、录制或广播等。公众因是消费者、再创作者或信息提供者而享有作品使用权，其使用权可规范作品的消费、再创作和信息提供等行为。三方主体的权利与义务互相支持和制约，形成全面的著作权法律规范体系，规定与调整著作权的基础法律关系。

（二）公众使用权规范的行为及利益

公众使用作品行为的范畴决定着公众使用权的范畴。针对消费者、再创作者和信息提供者，相应的作品使用行为包括作品消费行为、再创作行为和信息提供行为。针对这三种行为，公众皆可享有使用权，只是其法理基础及其与著作权或邻接权的关系有所不同。

第一，消费者为学习、研究或欣赏等目的之消费行为。作品消费行为涉及的主要法律问题是消费者在免费或有偿获得作品载体或表演的前提下，是否有权获得作品的思想或信息等内容用于学习、研究或欣赏。数字互联网时代，消费者的无偿获得行为可增加网站的流量从而使 ISP 获得广告收入，著作权人也可由此获利。消费

① 参见方新军：《权利客体的概念及层次》，《法学研究》2010年第2期。

② 参见吴汉东：《著作权合理使用制度研究》，第118—120页。

者虽然可能没有直接支付作品或其表演的对价，却付出了针对作品或广告的注意力，增加了网络流量，亦可视为付出了获得作品的成本。在其有偿或免费获得作品的载体或表演后，消费者对于作品内容的使用实质上利用的是作品的思想或信息，它们属于著作权法中的自由使用行为。此过程有利于作品传播，对于作者或传播者的精神或经济利益亦有促进作用。因此公众获得作品内容用于学习、研究或欣赏的行为，并不直接涉及著作权或邻接权，其实施并无法律上的障碍。

第二，再创作者为评论、戏仿或演绎等目的之创作行为。再创作者的行为可能涉及原作品的表达，从而落入原作者著作权的范畴，可引起原作者的著作权和再创作者的使用权的冲突，涉及是否属合理使用的判断，也尤其能够体现公众使用权的价值。处理权利冲突的基本原则是既要合理保护原作者的著作权，又需维护公众评论或演绎新作品的权利。这是再创作者的权利，也可能是任何人的权利。此亦美国《版权法》第 107 条规定的合理使用规则的主要涵义所在。我国《著作权法》第 22 条也规定创作者为介绍、评论某作品或说明某问题可在作品中适当引用他人的作品，或者可对设置在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画或摄影等再创作行为。

第三，信息提供者的信息提供行为。无论是现实社会还是互联网空间，皆需信息提供者向公众提供关于作品的信息，以便于其获得和使用，传统图书馆、数字图书馆或互联网信息搜索平台就是代表。传统图书馆的信息提供方式包括索引、检索、出借作品以及在特定情形下提供复印件。公共图书馆的行为一般属自由使用行为。数字图书馆可能提供在线检索、浏览或部分复制（下载）等服务。ISP 可通过搜索、索引、设置链接或网页快照等方式提供作品信息。如果是单纯的信息提供行为，其行为可属合理使用行为，如美国联邦法院在谷歌图书馆案中认为，谷歌虽然制作了原告图书的数字拷贝，但该使用既能够增进公众知识，又不会向公众提供原告作品或其衍生品的实质替代品，不会造成显著的市场替代，属合理使用，即使其商业性质和利益动机也不能否决这一点。^① 数字互联网下的文本和数据挖掘及其分析应用也可被视为一种信息提供行为，从而属于合理使用。^② 但是如果 ISP 的行为超越了合理界限，就可能落入作者的著作权范畴。

美国版权法学者在论证使用者权时主要考虑了两种行为，其一是消费者对于版权作品的自由使用，其二是演绎作品的作者对于原作品的合理使用。^③ 该界定与本文对于作品消费行为与再创作行为的论述得出的结论基本一致，从而提示研究者对

① See Authors Guild v. Google, 804 F.3d 202, 207, 229 (2nd Cir. 2015).

② See Michael W. Carroll, "Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful," *University of California Davis Law Review*, vol. 53, 2019, pp. 893, 896-897, 963.

③ See L. Ray Patterson and Stanley W. Lindberg, *The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights*, p. 193.

公众使用作品的行为有基础共识。在数字互联网和大数据时代，作品使用行为还应包括信息提供行为，这样方可使著作权法理论更能契合发展的社会现实，法律规范更有现实合理性，进而有效维护著作权法律规范的效力。

利益是权利的正当追求，亦是权利存在的必要性基础。作品的消费者或再创作者藉由作品的使用或再创作，不仅可以获得娱乐的感受或知识、思想和能力的提高，亦可有效参与社会文化活动，在精神利益或经济利益方面有所收获。信息提供者在为公众提供信息的同时亦可获得相应的经济或社会利益。使用者作为著作权制度不可缺少的主体，其消费作品的行为、再创作的行为和提供信息的行为，既是著作权法律规范下的基础行为，又属文化传承和创新行为，不仅维系着著作权制度运行，促进实现著作权法基本目标，还可有效支撑版权产业可持续发展。可见围绕着作品使用行为存在着广泛的个人利益、公共利益和社会利益。^① 这意味着，从权利的价值角度亦有助于论证公众使用权的必要性与正当性。

（三）公众使用权的类型化

在传统著作权法框架下，一些属公众使用权范畴的使用行为被界定为著作权的限制或例外，在法律实施中这可能导致对公众使用行为的限制性解释。如果从公众使用权的角度界定公众可以实施的作品使用行为，相应的法律规范设置及其实施效果就可能有所不同。在立法方面可选择为公众设置具体的使用权规范，该法律规范可引导司法裁判者采取开放式的法律解释与法律适用原则。根据公众使用权调整的行为范畴及其是否涉及与作者著作权的冲突，本文把公众使用权分为自由使用权和合理使用权两种基本类型。它们虽然都具有国际人权公约和宪法渊源，但又各自具有正当性基础。

在著作权法框架下，作者著作权的设置通常与个人消费者并无直接关系，因为著作权中的复制权、发行权、表演权和传播权更多的是和传播者相联系，其作用在于控制传播者的传播行为，而非消费者的作品消费行为。演绎权在表面上看更多的是和演绎作品的作者即再创作者相联系，但演绎作品的复制、发行、表演与传播又可受到传播者的控制。这意味着，赋予作者著作权的意义主要是为控制传播者对其作品的传播，而非使用者的使用。美国版权法学者认为，可通过区分使用作品和使用版权来解释合理使用行为，虽然使用版权一般涉及使用作品，但使用作品却未必涉及版权。^② 该路径可用于区分和界定公众的自由使用行为与合理使用行为以及相应的自由使用权与合理使用权。

① 参见罗斯科·庞德：《通过法律的社会控制》，沈宗灵译，北京：商务印书馆，2008年，第34—38页。

② See L. Ray Patterson and Stanley F. Birch, Jr., "A Unified Theory of Copyright," pp. 335-336.

第一，自由使用权。作品消费一般由作品载体购买合同或获得作品表演许可合同等所规范，交易可能是有偿或免费。作品消费合同一般许可或默示许可的作品使用行为，包括学习、研究或欣赏，就是作品的自由使用行为，其实质是获得作品的思想或信息等内容。藉由消费者支持，著作权人的经济利益可得到维护，从而实现著作权制度的激励效应。消费者根据消费合同所支付的经济、时间或注意力等成本，可视为他获得作品并有权进行学习、研究或欣赏的对价，它可构成公众自由使用权的法律基础。作品消费合同或相应的默示许可是约束双方权利与义务的法律依据。如果消费者支付了对价，获得了作品载体或观看现场表演的资格，但却不能自由学习、研究或欣赏作品，其自由使用权就可能受到妨碍。虽然交易双方的权利与义务属于合同约定或默示许可的范畴，相应的违约行为应该属于合同法或消费者权益保护法范畴，但也可能存在著作权人利用强势市场地位限制使用者自由使用作品的情形，如利用技术手段过分限制使用者对作品的使用，因此著作权法仍有介入的必要。如果著作权法明确赋予公众自由使用权，使用者或可据此主张自己的权利。这相当于解决了合同法等不能完善解决的问题，有利于维护公众自由使用作品的权利与利益。

自由使用权仅涉及使用者对作品的自由使用行为，不涉及作者著作权所控制的行为，即不涉及作品的复制、发行、公开表演、向公众传播和演绎等。使用者的自由使用行为，包括对于作品内容的学习、研究或欣赏以及相应的个人表演等行为，由于未落入著作权的范畴而不受著作权约束。我国《著作权法》第 22 条规定，个人为学习、研究、欣赏而使用作品的行为就属此类行为。部分信息提供行为也可能属自由使用，其法律基础包括发行权穷竭等，如作品载体的销售者（如网络书店）或再销售者的作品信息提供行为，或图书馆的图书出借行为等。自由使用行为不会实质影响或替代著作权人在作品复制、发行、表演、传播和演绎等方面的市场，因此不会影响作品的正当使用，也不会不合理地损及著作权人的合法利益，一般不用通过“三步检验法”予以检验。这也意味着，作者的著作权并非能够控制所有作品使用行为，自由使用行为构成著作权的例外，在公众的自由使用权和作者的著作权之间并无权利或利益冲突，自由使用无须经过著作权人许可，亦无须支付报酬。

第二，合理使用权。由合理使用权所规范的合理使用行为既包括对作品的批评或评论等行为，也包括部分信息提供行为。信息提供行为可能涉及对作品或其片段的复制、向公众传播乃至对作品的演绎（如摘要或缩编），在大数据时代还可能涉及文本与数据挖掘等。合理使用行为不仅涉及对作品的使用，从而可能影响或替代被使用作品的著作权市场，还可能涉及对著作权的使用，引起合理使用权与著作权的冲突。因此合理使用行为一般需要通过“三步检验法”检验，只有符合条件的使用行为才被认可属于合理使用行为。这是在国际著作权条约框架下各方

基本认可的解决合理使用权和著作权冲突的规则。除上述自由使用行为外，我国《著作权法》第22条还规定了多种合理使用行为。它们主要体现为公众在教育、科学、文化等领域的权利或利益，基本与宪法规定的国家义务和公民权利相对应。是否属合理使用的主要判断原则是：为个人或公益目的，作品的复制、表演、演绎基本可行，而发行或传播基本不行（帮助弱势群体文化发展除外）。这容易理解，因为没有发行或传播就没有著作权市场替代，也基本不会与作品的正当使用相冲突，也不会不合理地损及著作权人的合法利益。

从作品使用行为是否为作者的著作权所规范的角度看，自由使用基本属非受制于著作权的作品使用行为，合理使用基本属受制于著作权的作品使用行为，二者具有不同的正当性基础和法律规范依据。把公众的作品使用权类型化为自由使用权与合理使用权，一方面可使公众使用权得到界定，另一方面亦使其权利基础更为清晰，从而便于在著作权法下分别设置自由使用与合理使用法律规范。这样既方便维护公众的利益，也使著作权和邻接权的边界更为清晰，各方的权利与利益均得到合理保护。

四、公众使用权的边界与可诉性

（一）公众使用权的边界

著作权法下的三方主体各自获得权利的法理与规范基础并不相同。作者因创作作品获得著作权，传播者因传播作品享有邻接权。公众使用权的法理与规范基础包括国际人权公约和宪法规定的多项权利以及源于合同的对价等。在现实中，著作权的存在可能影响书籍、音像载体或在线播放许可的价格，但在这些价格中版权费的影响程度到底有多大难有统一标准。并且，作品是否处于著作权保护期与作品的可及性也无必然关系。即使是超过著作权保护期的作品，如果出版者不再出版且无处可借阅，或ISP不在网络上提供，消费者仍然无法获得相关作品。

在著作权、邻接权和公众使用权之间可能存在权利冲突，其权利或利益平衡至关重要，相应的法律规范需对此做出调整。这涉及权利的边界及其协调。虽然在现实的著作权制度下有创作者、传播者与使用者三方主体，但传统著作权法理论却更重视前两者的权利，而忽视使用者的权利，亦无著作权法律规范对公众使用权做出清晰规定。从权利冲突与协调角度看，各方主体均需尊重其他主体的权利，这样虽然各方主体的权利看似均受到限制，但却更可能达成著作权制度下各方的利益平衡，促进著作权法基本目标的实现。依据权利的内涵以及国际著作权条约的规定，著作权或邻接权一般能够控制作品的传播，因此如何界定公众使用权与它们的平衡就成为著作权法理论和规范需面对的问题。有著作权法专家强调，著作权法需维护作者

获得合理报酬的权利，但也需铭记公众亦是世界信息基础结构的成员，因此需要为之提供合理的信息可及性，以维护利益平衡。^① 权利或利益平衡是著作权法的一项基本原则，其实施需依赖于著作权法律规范的合理设置。

从作者角度看，为传播者或使用者的设置权利就是对著作权施加限制。在著作权法律规范体系下，对作者著作权施加的限制通常包括法定许可（或强制许可）和合理使用，前者主要针对传播者，后者主要针对消费者以及相应的公益机构、公务机构或商业机构。从传播者角度看，设置邻接权的目的在于保障其利益，进而促进作品传播，而作品的广泛传播又有益于扩大作品和作者的影响。法定许可虽然在表面上看属于对作者著作权的限制，但该制度除有利于作品的传播外，也可为作者带来经济利益，并且非自愿许可多是针对不易获得自由许可的情形而设置，亦有“三步检验法”作为制约机制保障作者著作权利益的实现。^② 同样的逻辑亦适用于对合理使用的分析。使用者虽然使用了作品，但其使用却可能符合公共政策目标，且不会影响作品的正当使用，也不会不合理地损及作者的合法利益。这些行为既可促进作品的传播和使用，从而有利于维护作者的著作权利益，又可激励作品的再创作和传播，促进文化传承与创新。

在著作权法基本目标指引下，虽然三方主体及其权利与义务互为依存，各自的权利皆需得到尊重和保护，但在其可能的冲突中，公众使用权应处于更为基础的地位。与著作权或邻接权的工具性与有限性相比，公众使用权更应具有基础性和开放性。在充分保护著作权或邻接权的前提下，公众使用权的边界应以维护使用者合理消费作品、再创作作品或提供信息的利益免受著作权或邻接权阻碍为限。在公众使用权得到充分尊重的基础上，公众也更有可能尊重作者的著作权和传播者的邻接权，保证其精神与经济利益得以实现。

（二）公众使用权的可诉性

厘清公众使用权的性质对于界定著作权法下合理使用等法律规范至关重要。如果公众使用权仅是一种体现使用者利益的客观权利，或者仅属使用者的特权，则合理使用仅能被视为侵犯著作权的例外，在诉讼中它也只能作为侵权抗辩手段。然而如果公众使用权具有法律救济措施，它就能够成为一种主观权利或霍菲尔德权利体系下的权利，使用者就可作为权利人主张相应的法律救济，公众使用权性质的界定因而与其可诉性密切相关。在现有著作权法律规范下，合理使用只是一

① Mihaly Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, Their Interpretation and Implementation*, para. 5.120.

② Mihaly Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, Their Interpretation and Implementation*, paras. 5.54, 5.58; 刘银良：《我国广播权法定许可的国际法基础暨修法路径》，《清华法学》2019 年第 2 期。

种客观权利即由法律所维护的利益，而不是一种主观权利，或者仅是霍菲尔德权利体系下的特权。^①

然而应认识到，无论是大陆法系的主观权利与客观权利，还是霍菲尔德的权利与特权，关键的判断要素是看该权利有无法律上的救济手段或可诉性，即当该权利受到侵害或妨碍时权利人可请求司法机关予以救济的法律措施。权利是主观权利或客观权利，是权利还是特权，仅取决于法律规定，与该权利的正当性渊源没有必然关系。或者说，权利的性质源于实在法的规定而非其法理基础，有法律的积极救济措施就是权利。如果某项权利具有法律的可诉性，就可认为它是一种主观权利或霍菲尔德概念下的权利。因此，公众使用权到底是特权还是权利，关键在于著作权法的规定及其适用性解释，而非该权利的法理基础。如果著作权法规定公众享有使用权并赋予其救济措施，它就可成为实在法下具有可诉性的权利。

在我国现行著作权法框架下，合理使用仅属作品使用者的客观权利或特权，它也仅能被理解为著作权的限制或侵权例外，使用者也仅能在侵权诉讼中把它作为抗辩事由或在不侵权之诉中作为主张事由。然而，为适应数字互联网以及相应的大众创作与传播时代，平衡著作权法的权利基础，著作权制度需做出因应性改进，规定作品使用者享有具有救济措施的作品使用权。在上述理论支撑下，著作权法仅需合理延伸，就可对公众使用权做出规定。^② 通过立法规定使用者的自由使用行为或合理使用行为不是侵权行为，乃至进一步明确规定公众享有作品使用权，就可使公众使用权得以在著作权法律规范中被固定，它也因而并非仅可用于侵权抗辩的特权，而是具有可诉性的权利。^③ 既然公众使用权属于使用者法定的权利，它就不能为著作权人或邻接权人所擅自剥夺或限制。

在立法纳入公众使用权的基础上，法院即可对其法律规范做出适用性解释，其中尤其是涉及著作权、邻接权与公众使用权的冲突与协调事宜。在传统著作权法理论框架下，使用者的合理使用行为通常被视为一种积极抗辩，但在公众使用权法律规范支持下，它就可成为积极的权利。^④ 例如在涉及数字互联网安全港规则的通知与删除程序及相应的法律救济的案件中，美国第九巡回法院认为，合理使用并非仅属积极抗辩，它完全是为法律所授权，是一种非侵权使用。既然合理使用人不是侵

① 参见朱理：《合理使用的法律属性——使用者的权利、著作权的限制还是其他》，《电子知识产权》2010年第3期。

② 例如美国版权法第107条规定，为批评、评论、教育、研究等目的复制作品的合理使用行为不是侵权行为。第108条规定该条不得以任何方式影响第107条规定的“合理使用”。See 17 USC 107, 108(f)(4).

③ See Ned Snow, “The Forgotten Right of Fair Use,” *Case Western Reserve Law Review*, vol.62, no.1, 2011, pp.135, 163-164.

④ See *Lenz v. Universal*, 801 F.3d 1126, 1133 (9th Cir. 2015).

权者，他因此并无侵权责任，无需藉由抗辩得到侵权责任免除。退一步讲，即使把合理使用归为积极抗辩，鉴于其在版权法中的独特地位，也应该把它和传统的抗辩区别对待。^① 版权法规定，如果作品使用者的使用因版权人或其代理人的虚假通知被错误删除并导致损失，版权人或其代理人就可能需为此承担赔偿责任。^② 法院认为，版权人在向 ISP 发出删除通知前必须主动地考虑他所举报的行为是否构成合理使用，而不是让被控侵权人确定是否构成，如果忽略了这点他就可能需承担赔偿责任。版权人形成相关使用行为不构成合理使用的善意认识即可。但如果版权人仅是在口头上说形成了不构成合理使用的善意认识，然而证据却相反，其行为就属于“明知地虚假陈述”，就需承担法律责任，使用者就可主张赔偿救济。^③

该案判决明确提出合理使用权是一种实在的权利，公众可享有法律上的合理使用权。如果版权人的虚假陈述行为导致使用者对作品的合理使用行为受到限制，合理使用人就可要求版权人赔偿其损失。这意味着，公众的合理使用权可有确定的法律救济措施，保证其在受到侵害或妨碍时有确实的可救济性。本案是合理使用权的里程碑式判决。它既证明合理使用不仅有侵权抗辩一种理论解释及规范路径，还提示具有可诉性的合理使用权并非不可实现的实在的权利。它既可以在著作权法律规范中得到合理设置，也可以在司法实践中得到正当维护。基于相同的逻辑，公众的自由使用权也可在著作权法下被设置为一种具有实际救济措施的权利，从而具有可诉性，藉以排除著作权人或邻接权人的可能侵扰。如果著作权法为其规定了具体救济措施，公众使用权完全可以成为具有可诉性的权利，藉以维护作品使用者在自由使用与合理使用方面的权利与利益。

结 语

在传统著作权法理论下，著作权制度有“作者—著作权”和“传播者—邻接权”两大基础，使用者虽然也属著作权制度的重要角色，但在著作权法理论中他们的价值却基本被忽略，也没有被赋予相应的权利。著作权法理论与制度的内在缺陷长期存在，并于数字互联网时代体现尤甚。然而使用者的角色却不容忽视，他们不仅支撑着版权产业，也是实现著作权法基本目标的基础力量。对著作权法律规范的改进需要涉及两方面的要素。其一，著作权法下的权利与义务主体不仅包括作品的创作者与传播者，还包括作品的使用者。其二，著作权法不仅需要赋予作者及传播者著作权和邻接权，也需赋予公众使用权。藉此，著作权法律规范才能够全面体现和涵

① See *Lenz v. Universal*, 801 F.3d 1126, 1132-1133 (9th Cir. 2015).

② See 17 USC 512(f).

③ See *Lenz v. Universal*, 801 F.3d 1126, 1132-1138 (9th Cir. 2015).

盖著作权制度的法律关系，著作权合理使用制度等缺陷才可能得到弥补，公共利益亦可望得到全面维护。

“公众—使用权”是著作权法的第三基础。赋予使用者权利就是赋予全体公众成员权利，因为每个公众成员都可能是著作权法下的作品消费者或再创作者，也可能成为信息提供者。著作权法明确赋予公众使用权的目的并非仅是便于作品使用者获得和使用作品，而是藉由利益平衡的路径促进作品及其内含的知识、信息或思想的广泛传播，最终有助于著作权法基本目标的实现。至此，围绕作者、传播者和使用者三方主体及其各自权利的三大基础均得以构建，其各自的权利与义务构成著作权法的基础法律规范。从著作权法律规范及其调整的法律关系看，针对作品的创作、传播和使用，分别对应着作者、传播者和使用者三方主体，他们各自的权利与义务构成著作权法的三大基础：“作者—著作权”旨在激励作品创作，构成著作权制度的创新基础；“传播者—邻接权”旨在激励作品传播，构成著作权制度的传播基础；“公众—使用权”旨在维护公众对于作品的正当使用，构成著作权制度的使用与再创新基础。三方主体的权利与义务互相支持，其各自的边界体现出著作权法下的权利与利益平衡。著作权法三大基础相对独立，又互相促进与支持，共同支撑着著作权法律规范体系。

基于重新阐释的著作权法基础理论，立法者及研究者或可重新审视著作权法律规范体系及其基本结构，以期构建更为公平与有效率的著作权制度，其中包括合理的公众使用权（包括自由使用权与合理使用权）制度。具体的规范设计和体系建构尚需进一步系统分析。鉴于本文讨论的著作权法理论及制度困境在不少国家乃至在国际著作权条约中皆存在，我国著作权法理论的探索以及著作权法律规范体系的重构，亦可望对国际社会的著作权制度发展提供创新的经验借鉴。

〔责任编辑：李树民〕

it cannot be attributed to either the mind or the body, we should examine the relationships among the three as well as their relationship with human beings when reconstructing an overall conceptual schema of human beings.

(8) The Generative Mechanism of Online Narratives and the Intertextuality of Their Group Communication

Sui Yan and Tang Zhongmin • 167 •

The complexity of online narratives and their important influence on events, attitudes, emotions, etc. in society reveal certain limitations in traditional narrative theory's explication of such narratives. Their generative mechanism is the logical starting point for understanding online communication. Event correlation, text assemblage and specific texts, as the organic structure of online narratives, shape the intertextual existence and dynamic accumulation of layers of the online text. The universal multidirectional co-construction of textual meaning forms around correlated events and between specific texts and the pre-text, post-text and synchronous text within the textual assemblage, while the textual object, the communicating subject and the online group communication context together build up the interpretive system of online narrative meanings. The generative mechanism and vitality of online narratives not only provide guarantees for the active nature of online communication, but have also become a huge variable in social development, profoundly influencing social communication and even our way of thinking.

(9) Public Use Rights in Copyright Law

Liu Yinliang • 183 •

Normative analysis can help us explore the foundations of the copyright system and critically examine the legal norms of copyright. "Author—copyright" and "publisher—neighboring rights" are the two pillars of traditional copyright law, in which the public basically plays a passive role. However, this does not reflect the reality of the copyright system, nor does it fully express its basic legal relationships. As users of the works, the public is an indispensable player and should have access to them. "The public—use rights" should become the third pillar of copyright law. These rights may be established under copyright law as justiciable rights with remedies. The three pillars of copyright law correspond to the creators, disseminators and users of works and their respective rights. The three players and their rights and obligations are mutually supportive, building a complete normative system of copyright law and advancing the basic goals of copyright law. We can expect that a copyright law based on the reinterpretation of the basic legal relationships of copyright in China will build a more fair, reasonable and effective copyright system and will also provide innovative experience to be drawn on in the development of the international community's copyright system.